

1525466-19.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" o entorpecente.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1525466-19.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525466-19.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AUGUSTO BAILONI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

LUCAS AUGUSTO BAILONI foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", do Código penal, porque, no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 16:20 horas, durante o período de calamidade pública, decorrente da epidemia do COVID-19 (Coronavírus), na Rua Alferes Magalhães, altura do nº 347, Santana, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 24 (vinte e quatro) recipientes de plástico contendo maconha, 20 (vinte) invólucros contendo maconha, 29 (vinte e nove) eppendorfs contendo crack, 01 (um) tijolo de maconha, 117 (cento e dezessete) eppendorfs contendo cocaína e 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais) em dinheiro e 01 (um) caderno com anotações da contabilidade do tráfico.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado em audiência, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora e a produção da prova oral.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente a fls. 14/15.

Laudo de Constatação a fls. 28/32.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 122/125.

Comprovante de depósito judicial do valor apreendido (R\$ 32,00) a fls. 111.

Proferida sentença condenatória (fls. 136/141), o acionado dela recorreu, por conduto da Defesa (fls. 155/170), recurso este devidamente contrariado (fls. 202/212), submetido a avaliação da Corte Paulista, sobrevindo v. Acórdão de fls. 231/240, sede em que negado provimento ao reclamo. Certificado o trânsito em julgado (fls. 248), baixaram os autos a este primeiro grau de Jurisdição, sendo tomadas as medidas pertinentes (fls. 252). Foi noticiada decisão Superior, cassando a sentença (fls. 279/293), com determinação.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ciente da r. decisão de fls. 279/293, resta o seu imediato cumprimento. Com efeito, pela Superior Corte de Justiça assim se assentou: "IV - Dispositivo. À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as provas delas derivadas, as quais deverão ser desentranhadas do processo, ressalvada, todavia, a apreensão de drogas realizada antes da entrada no quarto do paciente. Por conseguinte, casso a sentença e determino ao Juízo de primeiro grau que a refaça, sem levar em consideração as provas aqui reconhecidas como ilícitas e sem aplicar a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP" (fls. 277/293).

Passo, então, à nova avaliação do caso, na esteira da determinação Superior. A materialidade do crime ainda encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15, Laudo de Constatação de fls. 28/32 e Laudo Pericial de fls. 122/125, onde se infere que parcela dos materiais apreendidos com o acionado, por ele dispensados na via, antes de adentrar no local onde mantinha a morada, efetivamente, se tratavam de substâncias entorpecentes.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado optou pelo silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 20).

Em audiência, negou a acusação.

Afirmou, então, que na data dos fatos estava em sua casa, juntamente com sua esposa, momento em que um morador da pensão afirmou que haviam policiais que batiam à porta, o que não lhe assustou, pois, nada de errado fazia. Assim, tão logo aquele morador abriu o portão da habitação, os policiais se dirigiram ao seu quarto, já dizendo é você mesmo, é você mesmo, o levando preso, pese embora nada tivesse de ilícito consigo. Indicou, ainda, que os policiais agrediram sua esposa, grávida de oito meses, ameaçando leva-la presa, caso não assumisse as drogas. Por fim, narrou que os policiais quebraram a pensão inteira.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, isolado no contexto da prova, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir. Interessante que não trouxe para fazer ouvir em audiência uma única testemunha, o que não lhe faltava, na medida em que, de acordo com sua versão, a ação policial se deu dentro de pensão, na presença de sua esposa e outros moradores do local.

Triste investida!

Doutro lado, a prova, de todo séria.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Roberto Rocha Filho declarou que, na data dos fatos, na companhia de seu colega de farda encontravam-se em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo caminhando sozinho pela via pública, nas proximidades de um cortiço (pensão), o qual, ao perceber a aproximação das viaturas (ROCAM), acelerou os passos, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem. No entanto, o suspeito empreendeu fuga a pé para o interior da habitação coletiva, ao mesmo tempo em que jogou ao solo uma sacola plástica. O declarante e seu parceiro pegaram a referida sacola e continuaram a perseguição, logrando detê-lo no interior da pensão, sendo identificado como o acionado. Em busca pessoal a LUCAS, nada foi encontrado em seu poder, contudo, olhando a sacola que o mesmo havia dispensado na via pública, quando se evadiu, encontraram em seu interior

vários entorpecentes fracionados e dinheiro. Que indagou LUCAS a respeito das substâncias entorpecentes e do valor em dinheiro que o suspeito dispensou na via pública, tendo este confessado que realizava a mercancia das referidas substâncias a mando de terceiro, pelo que recebia valor em dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha Diego Borges Pereira, chamada a depor em Juízo, apresentou relato em absoluta consonância com a narrativa de seu parceiro de equipe.

Some-se, ainda, porque oportuno, a descrição fática descrita pelos policiais ao momento da prisão, perante a autoridade policial (fls. 16/19), onde se infere que naquela sacola dispensada pelo acionado na via, antes da fuga para o interior da sua habitação, foram encontradas vinte e cinco porções de maconha, seis porções de crack, além de cinco porções de cocaína, afora a quantia de trinta e dois reais. Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo, em meio à via pública, boa quantidade de drogas variadas (trinta e seis porções), marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter tal quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Interessante pontuar que sequer o acionado afirmou fazer uso de qualquer entorpecente.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A boa quantidade de drogas apreendidas, num total de trinta e seis porções de entorpecentes de natureza variada, embaladas de forma particularizada, prontas para a venda no "varejo", as circunstâncias do flagrante, dentre as quais, destaco a conduta absolutamente suspeita do réu, que, ao se ver na iminência de ser abordado pelas autoridades da lei, empreendeu fuga, dispensando as drogas e dinheiro na via, procurando abrigo no que chamava de lar, os depoimentos firmes dos policiais que abordaram o acusado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "trazer consigo" o entorpecente.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram desfavoráveis, a quantidade de drogas a ser considerada, na esteira da determinação superior, não se mostrando alentada, motivo pelo qual, com fundamento no art. 42 da Lei nº

11.343/06, fixo as penas-base no cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a quinhentos dias multa.

Em segunda fase, entendo ausentes atenuantes.

Contudo, em atenção ao decidido pela Superior Corte de Justiça, afastada a possibilidade de reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, presente a agravante decorrente da reincidência específica, consoante nos dá conta a certidão de fls. 79 (condenação pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos de nº 1515883-10.2020, que teve curso perante a 25ª Vara Criminal Central).

Assim, frente a tais ponderações, majoro as reprimendas em 1/6, encerrando o

cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa.

Sobre a questão, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURIDICAMENTE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO ENSEJA O INCREMENTO MAIOR QUE A USUAL FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO HC N. 365.963/SP. REGIME FECHADO. ACUSADO CIRCUNSTÂNCIA REINCENTE JUDICIAL E COM DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] IV - Alinhado à jurisprudência que se firmou no âmbito da Terceira Seção, extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. [...] (STJ, HC 578638 / SC, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J: 26/05/2020, DJe: 03/06/2020).

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, não sendo aplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em se tratando de acusado reincente específico.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincente específico.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincente que ostenta réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Assim, inviável aplicação de pena diversa da corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, dando cumprimento à decisão Superior, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu LUCAS AUGUSTO BAILONI ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de multa no valor equivalente a quinhentos e oitenta e três dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, sequer tisonada pela decisão de Corte Superior.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido nos autos a fls. 14/15 (R\$ 32,00), depositado a

fls. 111, ao FUNAD, posto que evidente produto do tráfico de entorpecentes. Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Comunique-se a presente decisão ao Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 686232/SP, nos termos da orientação de fls. 278.

Ainda, comunique-se a decisão de fls. 277/293, e a presente sentença, ao Juízo da Execução Criminal.

Intime-se MP e DPE, tal como o acionado, no ergástulo em que se encontra (Penitenciária Adriano Marrey - Guarulhos).

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06